

1502694-07.2020.8.26.0408

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Raquel Grellet Pereira

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/03/2022

... que foi condenado anteriormente por tráfico em 2012 e que naquela oportunidade também estava passando por dificuldades financeiras em razão de um distúrbio mental de sua mãe. Narrou que o corréu é seu sobrinho, mas que o considera como filho, porque ele foi abandonado pelos pais, e que (o corréu) não tinha nenhuma relação com o tráfico que estava praticando.

A versão dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

1ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários nº 1895, Ourinhos - SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0004182-42.2018.8.26.0408 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502694-07.2020.8.26.0408

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DENIS PEREIRA GALVAO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raquel Grellet Pereira Bernardi

Vistos.

PAULO OTÁVIO PEREIRA e DÊNIS PEREIRA GALVÃO, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Consta da denúncia que, no dia 08 de outubro de 2020, às 12h00, na residência localizada na Rua Eduardo Perez, n.º 1181, na Vila São Luiz, nesta cidade e Comarca de Ourinhos, os réus tinham em depósito, para fins de tráfico, 42 (quarenta e dois) papérolas e uma pedra bruta - com massa total de 126,11 gramas - de cocaína, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Os réus foram notificados (certidão de fl. 284) e a defensora constituída apresentou defesa preliminar (fls. 295/299).

A decisão de fls. 435/436 recebeu a denúncia, no dia 08 de fevereiro de 2021.

Os réus foram regularmente citados (certidão de fl. 464).

Durante a instrução, os réus foram interrogados e foram ouvidas duas testemunhas comuns e uma de defesa.

Em memoriais, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação dos réus nos termos da imputação contida na denúncia. A defesa suscitou preliminar de nulidade decorrente da interceptação da linha telefônica do réu PAULO em data anterior à da autorização judicial e, no mérito, requereu o reconhecimento da atenuante da confissão e a aplicação da causa de

diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, bem como, em relação ao réu DÊNIS, requereu a sua absolvição, sob o fundamento de insuficiência de provas do tráfico a justificar um decreto condenatório.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A preliminar de nulidade decorrente da interceptação da linha telefônica do réu PAULO em data anterior à da autorização judicial não merece acolhimento.

A interceptação foi autorizada nos autos n.º 0002733-78.2020.8.26.0408, que são físicos em razão de determinação das NSCGJ e se encontram arquivados em Cartório. A decisão que autorizou a interceptação da linha 99851-8909 foi proferida no dia 03 de setembro de 2020 (fls. 06/09) e no dia 04 de setembro de 2020 foi retificada para a correção de erro de digitação do número da linha (fls. 12/15).

Na sequência, no dia 22 de setembro de 2020 foi proferida decisão que prorrogou a interceptação da linha 99851-8909 e incluiu a linha 99861-0031 (fls. 31/32).

Às fls. 191/192, constam as conversas interceptadas nos dias 04 e 11 de setembro, na sequência 26 de junho e na sequência 12 e 29 de setembro de 2020.

No relatório final da interceptação, constou novamente a cronologia correta dos dias, mas novamente foi indicado 12 de setembro, 26 de junho e 29 de setembro (fl. 220).

Em contato com o investigador Alex de Moraes Alves Evangelista, responsável pelo relatório das interceptações dos autos, foi informado por ele que a conversa que constou por equívoco como tendo ocorrido no dia 26 de junho de 2020, às 16h25min28seg, na realidade foi interceptada no dia 26 de setembro de 2020, às 16h25min28seg, pelo sistema Guardião. Trata-se de explicação lógica, que não altera fatos nem fundamentos, mas sim apenas elucida o erro de digitação de fl. 192, reiterado à fl. 220, conforme correta indicação da defesa à fl. 616.

No mérito, a ação penal é procedente.

Encerrada a instrução, a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, foram inequivocamente comprovadas e ensejam a condenação dos réus.

A materialidade é comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 21/23, conjugado com o laudo de constatação provisória de fls. 37/39 e com o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 477/479.

A autoria, por sua vez, decorre das declarações dos réus, do depoimento das testemunhas ouvidas em juízo e das circunstâncias do caso concreto.

Interrogado em juízo, o réu DÊNIS negou a prática do tráfico. Afirmou que havia saído da Fundação Casa fazia aproximadamente dois meses e que estava morando com o corréu, que é seu tio, porque ele o ajudava, já que havia sido abandonado pelos seus pais. Disse que não sabia que o corréu estava traficando e que não tinha nenhuma relação com a substância entorpecente apreendida.

Por sua vez interrogado, PAULO confessou o tráfico, mas afirmou que tinha na sua residência apenas uma pequena porção de cocaína, que indicou aos policiais civis, bem como que as demais porções e a pedra bruta não eram suas. Disse que estava passando por dificuldades financeiras durante a pandemia e que por essa razão aceitou pegar a cocaína para revender. Inquirido pelo representante do Ministério Público, respondeu que foi condenado anteriormente por tráfico em 2012 e que naquela oportunidade também estava passando por dificuldades financeiras em razão de um distúrbio mental de sua mãe. Narrou que o corréu é seu sobrinho, mas que o considera como filho, porque ele foi abandonado pelos pais, e que (o corréu) não tinha nenhuma relação com o tráfico que estava praticando.

A versão dos réus não foi corroborada pelos demais elementos de prova dos autos.

O policial civil Alex de Moraes Alves Evangelista afirmou que receberam uma denúncia de que o réu PAULO estava traficando na sua adega, razão pela qual solicitaram autorização judicial para a interceptação de sua linha de celular.

Disse que em algumas conversas o réu se identificava como PAULO e conversava normalmente, o que permitia concluir que se tratava de negócios regulares de seu estabelecimento comercial, mas que em outras conversas não se identificava e usava termos que permitiam afirmar que não se tratava de conversas sobre produtos

regulares da adega, mas sim sobre substâncias entorpecentes. Narrou que PAULO negociava um tipo deferente de cocaína, que indicava como vermelho ou vinho vermelho, e que se dispunha a levar a droga aos locais em que os usuários se encontram. Em um diálogo, a pessoa pergunta se tem Heineken, ao que o réu responde que não, mas diz que tem vinho vermelho, ao que a pessoa lhe diz que vai passar para pegar. Em outra conversa, um usuário lhe pede duas caixinhas, cada uma por R\$50,00, que devem ser levadas a um drive, na Rodovia Raposo Tavares. O réu confirma que levará, mas na sequência o usuário afirma que não deu certo, porque a sua acompanhante descobriu que ele estava comprando cocaína e não havia concordado, ao que então o réu afirma que ele deve sair à frente do drive, que ele pode levar, ou que vá à sua adega para buscá-la. Disse que foram interceptadas duas conversas que comprovam o envolvimento de DÊNIS com o tráfico, sendo que em uma delas PAULO liga e pergunta onde ele está e DÊNIS lhe responde que está subindo, ao que então PAULO lhe diz para levar "quarenta real, porque já foi todo aquele dinheiro" e outra em que PAULO liga para um usuário e lhe pergunta se foi ele quem parou na frente da adega e ambos conversam sobre a cocaína, sendo que o usuário afirma que não gostou e quer saber da outra, ao que PAULO lhe pergunta o que DÊNIS falou e o usuário responde que DÊNIS lhe disse que "estava tendo, só que mais tarde". Afirmou que DÊNIS também teve a sua linha telefônica grampeada, mas que foi durante pouco tempo. Disse que no centro da tomada havia uma porção de cocaína parcialmente consumida e que PAULO afirmou que era usuário e que aquela porção era para o seu consumo. Narrou que lhe perguntaram se tinha mais e que ele respondeu que não. Afirmou que na sala foram encontrados diversos saquinhos ziplock com resquícios de cocaína e uma balança, cuja origem o réu não soube identificar. Disse que no quarto da mãe do réu foi localizada uma embalagem bem fechada contendo quarenta e uma porções de uma substância avermelhada com um cheiro muito forte, como o do crack, e que PAULO disse que não sabia do que se tratava e que a droga poderia ser de DÊNIS, porque ele estava dormindo no quarto de sua mãe. Narrou que o cão farejador da Polícia Militar localizou mais uma pedra bruta no quintal da casa. Afirmou que PAULO negou a propriedade da cocaína. Disse que apreenderam um aparelho de gravação das imagens da adega, tendo sido identificadas diversas entregas de invólucros por PAULO a usuários. Narrou que no celular foram identificadas diversas conversas entre PAULO e a namorada dele, Amanda, que deram ensejo à instauração de outro inquérito policial para a apuração dos crimes praticados por eles. Inquirido pela defesa, respondeu que havia dois veículos na residência, uma motocicleta de 1000 cilindradas e um Azzera preto, tendo ambos sido apreendidos. Inquirido especificamente pela defesa, respondeu que não havia um terceiro veículo na casa do réu.

Em que pesem as judiciosas alegações defensivas, inviável o acolhimento da tese que pretende a descaracterização da conduta criminosa de DÊNIS, que tinha participação ativa no tráfico a ponto de PAULO perguntar ao usuário para quem ligou no dia 29 de setembro o que DÊNIS havia falado, ao que o usuário responde que DÊNIS lhe disse que tinha, mas mais tarde (fl. 192).

Não se trata de conversa sobre itens regulares da adega, tendo em vista que na sequência o usuário pede a PAULO uma da outra e que PAULO responde que não está tendo, ao que o usuário afirma que não gostou e PAULO lhe diz que foi o único que não gostou (fl. 192).

Também a conversa que constou equivocadamente como ocorrida no dia 26 de junho, que na verdade foi interceptada no dia 26 de setembro, como esclarecido pelo policial civil responsável pelo monitoramento, permite concluir a atuação de DÊNIS no tráfico, já que, sendo PAULO o proprietário da adega, não seria lógico que pedisse a DÊNIS que lhe levasse R\$40,00 sob o fundamento de que "todo aquele dinheiro havia acabado".

As conversas interceptadas não trazem os nomes das substâncias entorpecentes por razões óbvias, mas por outro lado não fazem sentido na consideração do contexto, o que permite a conclusão de que se trata de diálogos referentes ao tráfico.

Não se desconsidera que Carlésia Francielle Domingos afirmou que trabalhou na adega de PAULO por quase dois anos e que vendiam cervejas e cigarros de vários tipos e

também faziam porções e espetinhos, mas se reafirma que os termos utilizados nas conversas específicas indicadas não dizem respeito a tais itens. Por fim, quanto aos valores e veículos apreendidos nos autos, trata-se de situação distinta.

Embora a adega tivesse movimento próprio, não é crível que a receita fosse guardada em dinheiro, o que não se verifica em relação ao tráfico, cuja remuneração cotidianamente é apreendida com os traficantes.

Tais circunstâncias permitem a conclusão de que os valores em dinheiro apreendidos eram decorrentes da atividade criminosa, o que justifica a decretação de seu perdimento em favor da União.

Por outro lado, quanto aos veículos apreendidos, não foram verificados em uso para o tráfico, ainda que tenha sido referida a entrega em um drive-in, que, pelo que consta, não aconteceu.

Sob tais fundamentos, os veículos deverão ser liberados para a pessoa a ser indicada pelo réu PAULO, sem custas, após o trânsito em julgado.

Provas da materialidade e a autoria, evidenciou-se a prática, pelos réus PAULO OTÁVIO PEREIRA e DÊNIS PEREIRA GALVÃO, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Passo à aplicação de suas penas.

Nem a natureza da cocaína e nem a sua quantidade justificam o aumento da pena-base. Nesse sentido, em caso análogo em que o apelante tinha 106,25 gramas de cocaína, o voto do Desembargador Guilherme de Souza Nucci, da 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, na Apelação Criminal n.º 1500102-50.2021.8.26.0603, da Comarca de Araçatuba, em julgamento ocorrido no dia 11 de agosto de 2021:

"Na primeira fase da dosimetria, as basilares do recorrente foram fixadas à fração de um sexto acima dos mínimos legais, em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, da natureza da droga apreendida.

A fundamentação utilizada pelo juiz sentenciante, contudo, não convence, tampouco justifica o gravame da pena-base, porquanto, além de não representar volume exorbitante, toda substância ilícita é nociva à saúde do consumidor, sob pena de se transformar o aumento das bases em medida constante, ao arrepio da individualização da pena.

No mais, não consta na Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, da ANVISA, uma gradação das substâncias, mas apenas uma relação de quais são ilícitas. O estudo acerca do potencial lesivo de cada substância, além de divergente, depende da frequência do consumo e das condições de saúde de cada usuário.

Dessa forma, em atenção ao artigo 59, do Código Penal, ausentes elementos que comprovem ser as circunstâncias judiciais desfavoráveis, tratando-se de réu primário e sem antecedentes, as bases são fixadas em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa."

Quanto ao réu PAULO, em primeira fase, atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em segunda fase, considero a agravante da reincidência (Processos n.º 9620-54/2015, na certidão de fls. 93/94, n.º 2835-81/2012, na certidão de fl. 94, n.º 6684-37/2014, na certidão de fl. 95, n.º 8313-41/2010, na certidão de fls. 96/97, e n.º 9620-54/2015, na certidão de fls. 97/98) e a atenuante da confissão, embora parcial, tendo em vista a negativa de coautoria de DÊNIS, o que ficou comprovado pelos elementos de prova dos autos.

Tendo em vista o disposto no artigo 67 do Código Penal, considero a agravante preponderante e, tratando-se de réu não apenas multirreincidente, mas também reincidente específico, aumento a pena em 1/2 (um meio), resultando 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Torno a pena definitiva, em razão da inexistência de causas de aumento e de diminuição.

Tratando-se de multirreincidente e reincidente específico (Processo

n.º 2835-81/2012, na certidão de fl. 94), inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, tendo em vista a conclusão inequívoca de sua dedicação reiterada a atividades criminosas e ainda especificamente à atividade criminosa do tráfico.

A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente em regime fechado (artigo 20, §1º, da Lei n.º 8.072/90, com a redação da Lei n.º 11.464/07), observados os critérios legais para a progressão de regime de acordo com a situação do ora condenado (artigo 20, § 2º, da Lei n.º 8.072/90, com a redação da Lei n.º 11.464/07).

O réu não poderá apelar em liberdade. Considera-se que foi preso em flagrante e que a prisão foi convertida em preventiva, o que demonstra a existência do *fumus boni iuris*, que, com a prolação desta sentença, tornou-se evidente.

A manutenção da prisão tem por fundamento a garantia da ordem pública, já que o réu, que é reincidente específico, além de multirreincidente, está sendo novamente condenado pela prática do crime de tráfico, que sustenta o crime organizado e é responsável pelo estímulo à prática criminosa.

Quanto ao réu DÊNIS, em primeira fase, atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em segunda fase, considero a atenuante da menoridade relativa. Mantenho a pena no mesmo patamar, tendo em vista que as atenuantes não ensejam a redução da pena aquém do mínimo legal fixado.

Em terceira fase, considero a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06.

Embora o réu não registre antecedentes, havia deixado a Fundação Casa dois meses antes dos fatos, tendo cumprido medida sócio-educativa de internação por ato infracional equiparado ao crime de tráfico, o que por si permite a conclusão de que não deixou a prática criminosa.

Consideradas tais circunstâncias, aplico a redução na proporção de 1/2 (um meio), resultando 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Afastada a hediondez da conduta tipificada como de tráfico, mas considerada a continuidade de sua prática, o regime a ser fixado seria o semiaberto. Por outro lado, tendo em vista o período pelo qual o réu permaneceu preso e não se tratando de crime praticado com violência, fixo o regime aberto para o início do seu cumprimento.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos por considerá-las insuficientes para o caso concreto, bem como porque o contato, tanto na Central de Penas e Medidas Alternativas como nos locais de prestação de serviços à comunidade, de um condenado por tráfico com outros condenados por crimes contra o patrimônio – que na maioria das vezes têm como fundamento o vício, que impulsiona o tráfico – tende a agravar a situação de todos eles, permitindo a reiteração das respectivas condutas, o que não pode ser considerada medida de boa política criminal.

Ausentes nesta fase os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO:

I - O réu PAULO OTÁVIO PEREIRA, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, inicialmente em regime fechado, bem como ao pagamento de 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, calculados no valor unitário mínimo e devidamente corrigidos a partir da data do crime.

O réu não poderá apelar em liberdade. Recomende-se-o no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.

Para fins de proibição do benefício do livramento condicional, nos termos do artigo 44, parágrafo único, da Lei n.º 11.343/06 ("Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos. Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput deste

artigo, dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de dois terços da pena, vedada sua concessão ao reincidente específico”), fica consignado que o réu PAULO é reincidente específico (Processo n.º 2835-81/2012, na certidão de fl. 94).

II - O réu DÊNIS PEREIRA GALVÃO, como incurso no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, inicialmente em regime aberto, bem como ao pagamento de 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, calculados no valor unitário mínimo e devidamente corrigidos a partir da data do crime.

O réu poderá apelar em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Com fundamento no artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União do valor apreendido nos autos (fl. 21). Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Banco do Brasil para que providencie a sua transferência ao FUNAD.

Quanto aos veículos apreendidos nos autos (fls. 27/28), serão liberados a quem for indicado pelo réu PAULO, independentemente do pagamento de taxas, após o trânsito em julgado.

Quanto aos demais objetos apreendidos nos autos (fls. 21/23), tratando-se de objetos relacionados ao crime de tráfico, determino o seu encaminhamento para destruição também após o trânsito em julgado.

Por fim, ainda após o trânsito em julgado, comunique-se a condenação ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins de suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

P.I.C.

Ourinhos, 04 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA